

1500190-44.2022.8.26.0574

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LEONARDO LABRIOLA FERREIRA MENINO

Comarca: Avaré

Foro: Foro de Avaré

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/11/2022

... pág. 209/210). No mesmo sentido a jurisprudência:

"TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PROVA BASTANTE - CONDENAÇÃO MANTIDA - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO NÃO CARACTERIZADA - CONDENAÇÃO AFASTADA DE OFÍCIO COM EXTENSÃO AO CO-RÉU - APELAÇÃO DESPROVIDA. Para a existência do crime de tráfico basta a guarda da substância entorpecente, não sendo exigível a prova da efetiva venda da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Avaré

Foro de Avaré

1ª Vara Criminal

Rua Abílio Garcia, 527, Avare-SP - cep 18706-047

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500190-44.2022.8.26.0574 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500190-44.2022.8.26.0574

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial, Inquérito Policial - 2164194/2022 -

DEL.SEC.AVARE PLANTÃO, 25603825 - DEL.SEC.AVARE PLANTÃO, 2164194 - DISE-

DEL.SEC.AVARE, 037/2022 - DISE - Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de

Avaré, 2164194-28.2022.120122 - DISE - Delegacia de Investigações Sobre

Entorpecentes de Avaré

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ODAIR CARDOSO DOS SANTOS e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LEONARDO LABRIOLA FERREIRA MENINO

VISTOS.

ODAIR CARDOSO DOS SANTOS, vulgo "Dai", e BRUNO CAMPOS CALIXTO, já qualificados nos autos, foram denunciados pelo Ministério Público como incurso nas sanções dos artigos 33, "caput", e 35, "caput", ambos da Lei 11.343/06, sob a acusação de que, em dia e horário indeterminados, porém no início do mês de junho de 2022, na Rodovia Salim Antônio Curiati, 2, barracos às margens da linha férrea, Parque

Industrial Jurumirim, neste município e comarca de Avaré, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime previsto no artigo 33 da Lei 11340/06. Consta, ainda, que na madrugada de 17 de junho de 2022, por volta de 01h30min, no mesmo local acima apontado, neste município e comarca de Avaré, traziam consigo e tinham em depósito 18 (dezoito) porções de maconha, com peso aproximado de 21,02 (vinte e um gramas e dois centigramas), 19 (dezenove) porções de cocaína, com peso de 13,17g (treze gramas e dezessete centigramas), 05 (cinco) porções de cocaína, com peso de 8,50g (oito gramas e cinquenta centigramas), 1.035 (um mil e trinta e cinco) porções de cocaína, pesando 623,67g (seiscentos e vinte e três gramas e sessenta e sete centigramas), 324 (trezentas e vinte e quatro) porções de maconha, com peso de 379,23 (trezentos e setenta e nove gramas e vinte e três centigramas), 01 (uma) porção em pó de cocaína, pesando 18,01g (dezoito gramas e um centigrama) conforme laudo de exame químico-toxicológico às fls. 155/163, substâncias que causam dependência, o que faziam em desacordo com norma legal ou regulamentar (portaria 344/98 SVS/MS).

Auto de prisão em flagrante e demais peças do inquérito policial a fls. 01/166. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva a fls. 120/123. Mandados de prisão cumpridos a fls. 144/147. A denúncia foi oferecida em 30 de junho p.p. e os réus, devidamente notificados (fls. 213 e 215), apresentaram Defesa Prévia (fls. 220). Não sendo o caso de absolvição sumária, a denúncia foi recebida em 15 de agosto de 2022, ocasião em que também foi designada audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento (fls. 221/223). Em audiência, foram inquiridas 02 testemunhas de acusação e os réus interrogados (fls. 310/311 e gravações audiovisuais). Em sede de alegações finais, o Ministério Público postulou pela condenação dos réus nos exatos termos da denúncia (fls. 318/324). A Defesa dos réus Odair e Bruno, pugnou, em sede preliminar, pela nulidade do feito ante a violação de domicílio. No mérito, pleiteou pela absolvição com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP e, em caso de eventual condenação, pela fixação da pena em seu patamar mínimo legal, pela fixação do regime, substituição por pena restritiva de direito e possibilidade de recorrer em liberdade (fls. 333/351).

É, sucinto o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Segundo a inicial acusatória, "o denunciado ODAIR é oriundo de São Paulo e se estabeleceu em Avaré com o intuito de praticar o tráfico de drogas, motivo pelo qual se associou a BRUNO para tal fim. Assim é que ODAIR ficava incumbido da produção, fracionamento e contabilização das substâncias ilícitas, enquanto a BRUNO restou a tarefa de vendê-las aos usuários. Na data dos fatos, BRUNO trazia consigo 05 (cinco) porções de cocaína em tubos eppendorf e tinha em depósito nas imediações da linha férrea outras 18 (dezoito) porções de maconha e 19 (dezenove) porções de crack, ocasião em que dispensou parte das drogas ao avistar policiais militares que realizavam incursão a pé nas imediações visando reprimir o tráfico de drogas. Em continuidade às diligências, sabedores da associação firmada entre os denunciados, os policiais se deslocaram até o imóvel de ODAIR aos fundos para o Km 2 da Rodovia Salim Antônio Curiati. ODAIR trazia consigo oito porções de crack e em um cômodo nos fundos se constatou que ele e BRUNO tinham em depósito outras 1.027 (um mil e vinte e sete) porções de crack, 324 (trezentas e vinte e quatro) porções de maconha, R\$ 454,00 (quatrocentos e cinquenta e quatro reais) em espécie e notas diversas, 3.258 (três mil, duzentos e cinquenta e oito) embalagens plásticas para acondicionamento de drogas, 933 (novecentos e trinta e três) tubos plásticos do tipo Eppendorf, além de três rádios comunicadores, seis cadernetas, um caderno de anotações, um estilete, uma faca, mais uma quantidade de cocaína, que ainda não havia sido fracionada para venda. Mediante busca pessoal, foram encontrados, também, um aparelho de telefone celular com BRUNO e dois telefones celulares com ODAIR. A quantidade de droga apreendida, sua forma de acondicionamento e as circunstâncias da prisão indicam que os entorpecentes se destinavam ao fornecimento e entrega ao consumo de terceiro, estando os ora denunciados associados para tal finalidade". De prôemio, a preliminar de nulidade de provas alegada pela Defesa não merece prosperar. A entrada dos policiais na residência do corréu Odair não ocorreu de forma irregular, tampouco o flagrante foi ilegal não havendo, pois, se falar em

irregularidade e/ou nulidade.

Ora, o ingresso dos policiais na residência sem autorização judicial não está eivado por qualquer mácula. Primeiramente, porque não há comprovação de que a entrada não foi permitida. De fato, não há qualquer menção nos autos de resistência ao ingresso dos agentes por parte dos residentes.

Em adição, o artigo 5º, XI, da Constituição Federal prevê que a busca domiciliar não prescinde de mandado judicial, salvo nas hipóteses excepcionais, constitucionalmente previstas, dentre elas o caso de flagrante delito. Como é cediço, o ato análogo ao tráfico de entorpecentes é crime permanente e, em caso de flagrante de crime dessa natureza é possível a realização de busca domiciliar sem mandado judicial.

Assim, era perfeitamente lícito aos policiais, incumbidos do combate à criminalidade, adentrar na casa onde a droga estava sendo fracionada. Não se pode cogitar, por conseguinte, na ilicitude das provas obtidas, pois o momento consumativo do delito de traficância se prolonga no tempo. A respeito da prescindibilidade do mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, há sedimentada jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal: "A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados" (RE nº 603.616/TO; Relator Ministro Gilmar Mendes). Nesse sentido, já se posicionou o Tribunal de Justiça de São Paulo:

"Apelação Criminal -Tráfico de entorpecente- Nulidade do processo e da prova coligida porque a busca domiciliar fez-se sem autorização judicial -Inexistência Tráfico de entorpecente na modalidade "ter em depósito" é crime permanente - A ocorrência de flagrante delito justifica a busca domiciliar sem autorização judicial -Tipificação- A prova oral, a quantidade e a variedade de forma do entorpecente apreendido em poder dos réus asseguram que a droga se destinava à venda . Consumação .Para a consumação do crime do artigo 33 da Lei n.º 11.343/06, de ação múltipla, é desnecessário surpreender o agente em ato de mercancia, bastando que haja conduta que se ajuste a um dos verbos do tipo penal (misto alternativo Ausência de elementos seguros a indicar que os acusados estivessem associados para traficar Liame subjetivo de caráter estável não caracterizado Recursos desprovidos" (Apelação Criminal n.º 990.08.160355-1 rel. Desembargador José Raul Gavião de Almeida) (g.n.).

Ora, finda a instrução processual, restou claro que a abordagem foi motivada pela suspeita de traficância.

Inquestionável que a ação dos agentes da lei se revestiu de fundada suspeita, em conformidade com o artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, sendo descabida a aventada ilegalidade da busca pessoal.

No mérito, à luz da prova produzida, a denúncia procede parcialmente.

A materialidade delitiva está substanciada no auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 08/13), no auto de exibição e apreensão a fls. 16/17, fotografias de fls. 59/60 e 72/84, laudo de constatação provisória a fls. 67/71, laudo de exame químico-toxicológico a fls. 155/163, bem como por toda prova oral produzida em juízo.

A autoria, de igual modo, restou incontestada e recai sobre os réus tão somente em relação ao crime de tráfico de drogas.

O policial militar Raphael Fernandes Borges, policial militar, em juízo, confirmou os fatos tais como descritos na denúncia. Disse "que havia denúncias da associação firmada pelos acusados, de modo que Odair se incumbia da distribuição e preparo de drogas, ao passo que Bruno se responsabilizou pela venda. Durante a abordagem observou que o acusado Bruno dispensou um objeto no chão, que constaram ser pinos de drogas. Bruno assumiu trabalhar para o acusado Odair. Bruno não quis delatar a residência de Odair, mas já possuíam essa informação decorrente das notícias recebidas. Gravaram a autorização do réu Odair para a incursão na residência. Havia grande quantidade de drogas no local e ele confirmou que se destinava ao tráfico e que era oriundo de São Paulo para tal fim. Havia anotações de valores e

destinatário. Inclusive, havia balanço das vendas de Bruno".

A testemunha Rodrigo Mimoso Peres Ramos, policial militar, em juízo, reprisou a assertiva de seu colega. Acrescentou "que o acusado Bruno indicou a existência de mais drogas embaixo da linha férrea e que havia grande quantidade de droga e de pinos utilizadas para embalagem".

O réu Bruno, em seu interrogatório judicial, contou "que adquiriu as drogas em Itai e que não vendia para o acusado". Disse que certa vez comprou drogas de Odair, em uma ocasião. Falou que recebeu informações de que o acusado Odair vendia através de usuários. Não sabe se Odair tinha outros vendedores. Afirmou que vendeu drogas por necessidades financeiras".

O acusado Odair, em seu interrogatório judicial, confessou "que pratica o crime de tráfico de drogas, mas negou a associação com o acusado BRUNO".

Pois bem, as provas colhidas em juízo apontam para a ilícita mercancia praticada pelos réus. A tipificação do crime de tráfico de drogas, in casu, extrai-se do local da prisão (conhecido ponto de venda de drogas), das circunstâncias da prisão, da quantidade de droga apreendida (com réu Bruno: 18 porções de maconha, 19 pedras de crack, 05 eppendorfs de cocaína; com réu Odair: 1.035 eppendorfs de cocaína, 324 porções de maconha e uma porção de cocaína), do modo pelo qual estava acondicionada, 3.258 embalagens plásticas, 933 tubos plásticos, 03 rádios amadores, 06 cadernetas de anotação, 01 estilete, 01 faca, bem como a localização de dinheiro, cuja origem lícita os réus não comprovaram.

Com efeito, a admissão pelos acusados de que praticavam o tráfico de drogas representa dado relevantíssimo na formação da convicção, máxime se valorizado seu poder de convencimento pelo restante da prova colhida tal como se verifica no presente caso, nada existindo no sentido de infirmá-la ou fragilizá-la.

Nesse passo, cabe ressaltar que o depoimento prestado pelos policiais é, em essência, coerente e harmônico com as provas acostadas aos autos, bem como com a versão prestada pelo réu em seu interrogatório, que caminhou no mesmo sentido do alegado pelos policiais. É de se asseverar que o simples fato da testemunha ouvida ser policial nada significa para que seja desconsiderado seu depoimento ou que este seja recebido com reservas. Imprescindível salientar que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que os depoimentos de policiais ou agentes públicos em geral, apenas pela sua condição, não podem ser desconsiderados ou desacreditados, em primeiro lugar porque, constitucionalmente, são eles aptos, como qualquer cidadão, a presar testemunho sob o compromisso da lei. De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública o direito (e o dever) de prestar contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento.

A desconsideração de depoimento somente procede quando decorrente de atos de parcialidade, motivados por vingança ou perseguição e desde que comprovados de forma segura e objetiva, o que efetivamente não se evidenciou nestes autos.

Ressalte-se, por fim, que a diligência policial a qual culminou com a apreensão do entorpecente, somente ocorreu devido à divergência constante na cor do veículo descrita no documento. Confira-se:

"PROVA - Testemunha - Policial Militar - Validade - Reconhecimento -

Impossibilidade de invalidar o depoimento de Policial Militar, por suspeito ou impedido de depor, só porque ostenta essa qualidade, uma vez que, seria incurial, um verdadeiro contrassenso, o Estado credenciar alguém como seu agente e, ao depois, quando este prestasse conta de suas diligências, fosse taxado de suspeito - Recurso improvido." (Apelação Criminal n. J. 103.338-3/6 - São Paulo 9ª Câmara Criminal - Relator: Ubiratan de Arruda - 30.1.2008-V.U.)

Considere-se ainda que, em casos de crimes graves, como o tráfico de entorpecentes, a grande maioria das pessoas evita servir como testemunha, imperando verdadeira lei do silêncio, razão pela qual desprezar os depoimentos policiais nesses casos implicaria consagrar a total impunidade.

Ressalto, ainda, que para caracterização do crime de tráfico de drogas não é indispensável que o agente seja flagrado realizando o comércio de drogas. O tipo penal do art. 33, "caput", da Lei n. 11.343/2006 é de conteúdo múltiplo e define crime de perigo abstrato. Dessa maneira, basta a conduta de "guardar, ter em depósito, trazer consigo", desde que evidenciada a finalidade de entrega a

terceiro, para que o crime em questão reste caracterizado. E, no caso, essa finalidade está bem evidenciada, eis que a quantidade de droga apreendida (com réu Bruno: 18 porções de maconha, 19 pedras de crack, 05 eppendorfs de cocaína; com réu Odair: 1.035 eppendorfs de cocaína, 324 porções de maconha e uma porção de cocaína) é fator considerável à caracterização do tráfico, tornando-se incabível falar em desclassificação para o crime de posse de drogas. Nesse sentido:

"... não é indispensável a prova efetiva e direta de qualquer ato de comércio clandestino de droga, bastando o conjunto de indícios e presunções que, saliente-se, são claros e convergem contra o acusado, não podendo o juiz desprezar as regras de experiência comum (praesumptiones hominis), ou seja, a ordem normal das coisas, representando aquelas o conhecimento adquirido pela prática e observação do cotidiano." (TJSP, Apelação n. 0019906-40.2012.8.26.0071, rel. Julio Caio Farto Salles, j. 11/12/2014) (g.n.).

...

"a noção legal de tráfico de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização" (STF, 1ª T. H.C. nº 69.806/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Diário da Justiça, Seção I, 04/06/1993, p.11.012)

De maneira diversa, em relação ao crime de associação para o tráfico (art. 35 da lei de Drogas), observo que não prova acerca do suposto "animus" associativo entre os réus. Evidenciou-se mais um caso de concurso de pessoas, já que não restou comprovado nestes autos a estabilidade e permanência do tráfico em conjunto. Nesse sentido vem ensinando a doutrina: "não será toda vez que ocorrer o concurso que ficará caracterizado o crime em tela. Haverá necessidade de um animus associativo, isto é, um ajuste prévio no sentido da formação de um vínculo associativo de fato, uma verdadeira *societas sceleris*, em que a vontade de se associar seja separada da vontade necessária à prática do crime visado. Excluído, pois, está o crime, no caso de convergência ocasional de vontades para a prática de determinado delito, que estabeleceria a coautoria" (Tóxicos, Vicente Greco Filho, Editora Saraiva, 14ª edição, pág. 209/210). No mesmo sentido a jurisprudência:

"TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PROVA BASTANTE - CONDENAÇÃO MANTIDA - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO NÃO CARACTERIZADA - CONDENAÇÃO AFASTADA DE OFÍCIO COM EXTENSÃO AO CO-RÉU - APELAÇÃO DESPROVIDA. Para a existência do crime de tráfico basta a guarda da substância entorpecente, não sendo exigível a prova da efetiva venda da droga, razão pela qual a simples alegação de ser usuário não basta, por si só, para operar a pretendida desclassificação, mormente quando isolada do conjunto probatório, incumbindo ao réu provar que a substância se destinava para exclusivo consumo pessoal. O crime tipificado no artigo 35 da Lei 11.343/2006 não se configura diante de uma associação meramente eventual, mas apenas quando ela for estável e duradoura, ligada pelo animus associativo dos agentes, formando uma verdadeira *societas sceleris* que não se confunde com a simples co-autoria. Não tendo restado caracterizado que a associação era reiterada, a conduta deve ser considerada mais como uma consequência da ação única que deu origem ao tipo principal que é o tráfico de substância entorpecente. (TJ-PR - ACR: 4866746 PR 0486674-6, Relator: Rogério Coelho, Data de Julgamento: 18/09/2008, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ: 7743) (destaquei)

Por fim, no que tange aos argumentos Defensivos, no sentido de que não há provas suficientes para a condenação, são eles precários, insubsistentes e revelam-se desamparados ante o quadro acusatório firmemente consolidado nos autos. Em verdade, a simples alegação de ausência de provas não é suficiente para afastar a responsabilidade imputada, carecendo de um mínimo qualquer de credibilidade a autodefesa, destituída que foi e é de qualquer alicerce. Ademais, não demonstrou vício no flagrante e no resultado da persecução.

Diante do exposto, por esses fundamentos e mais o que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal e, em consequência, CONDENO os réus ODAIR CARDOSO DOS SANTOS e BRUNO CAMPOS CALIXTO, já qualificados nos autos, como incurso nas sanções do artigo 33, "caput", da lei 11.343/06. Por fim, ABSOLVO os réus ODAIR CARDOSO DOS SANTOS e BRUNO CAMPOS CALIXTO, já qualificados, da imputação que lhes foi feita como incurso no art. 35, "caput", da lei 11.343/06, o que faço com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Resta dosar a pena

de acordo com o critério trifásico adotado pelo Código Penal.

Primeiramente, em relação ao réu Bruno Campos Calixto, atento aos ditames do artigo 42 da Lei de Drogas, bem como aos elementos preconizados pelo artigo 59 do Código Penal e à sua primariedade (F.A. e certidões a fls. 181 e 254/255), fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, ante a falta de elementos sobre a real situação econômica do réu (CP, arts. 49 e 60). Na segunda fase, embora presente a confissão, deixo de reconhecê-la, eis que a pena já fora fixada em seu patamar mínimo legal. Ausentes quaisquer outras circunstâncias agravantes e/ou atenuantes. Na terceira fase, entendo que se faz necessário o reconhecimento da diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, pois o réu é primário e não há nos autos notícias de que participe ou integre associação e/ou organização criminosa, até porque, com ele não fora encontrado a maioria dos entorpecentes apreendidos (18 porções de maconha, 19 pedras de crack, 05 eppendorfs de cocaína). Assim, diminuo a pena anteriormente imposta em 2/3 (dois terços) resultando em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. Não estão presentes mais causas de aumento ou de diminuição da pena. Portanto, fixo em definitivo a pena a cumprir de 01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO e PAGAMENTO DE 166 (cento e sessenta e seis) DIAS-MULTA, com o dia unitário no piso mínimo legal.

Pese contrário ao entendimento deste Magistrado, necessário apontar que o regime inicial deverá ser o ABERTO, conforme recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, exarado no bojo do HC n. 596603-SP, no qual houve determinação para imposição de regime inicial aberto para cumprimento de pena, inclusive em relação a fatos futuros, na hipótese de condenação por tráfico privilegiado, nos termos do artigo 33, §2º, do Código Penal. Confira-se (...) Aos condenados que atualmente cumprem pena e aos que vierem a ser sancionados por prática do crime de tráfico privilegiado, determinar que não se imponha - devendo haver pronta correção aos já sentenciados - o regime inicial fechado de cumprimento da pena. (STJ - HC: 596603 SP 2020/0170612-1, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j. 04/08/2020). Tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal - HC 118.533 - reconheceu que o delito em questão não é mais hediondo, entendo viável a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Desta forma, faço a substituição da pena privativa de liberdade anteriormente fixada por duas restritivas de direitos. Assim sendo, observado o disposto pelo artigo 44, parágrafo 2º, 2ª parte e na forma dos artigos 45, parágrafo 1º e 46, todos do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam, a de Prestações de Serviços à Comunidade e de Prestação Pecuniária, por se revelarem as mais adequadas ao caso, sendo aquela consistente em tarefas gratuitas a serem desenvolvidas, pelo prazo da condenação, junto a entidade determinada pelo juízo da execução, devendo ser cumprida à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, que será distribuída e fiscalizada, de modo a não prejudicar a jornada de trabalho do condenado, sem prejuízo da multa já fixada e a prestação pecuniária no valor de um terço do salário mínimo nacional da época da infração penal, sendo destinada para entidade beneficente também indicada pelo juízo das execuções penais.

Ao Juízo da Execução, após o trânsito em julgado desta decisão, caberá fiscalizar a entidade beneficiada com a prestação de serviços, a qual deverá ser comunicada a respeito, através de seu Representante, com remessa de cópia da presente sentença, incumbindo-lhe encaminhar mensalmente relatório circunstanciado, bem como a qualquer tempo, comunicar sobre a ausência ou falta disciplinar da condenada, consoante disposto pelo artigo 150 da Lei nº 7.210/84.

Deverá, ainda, ser cientificado que ao condenado é facultada cumprir a pena substitutiva em menor tempo (artigo 55, do Código Penal), sendo que, nunca inferior à metade da pena privativa de liberdade fixada ou restante.

De acordo com o artigo 387, parágrafo único do CPP, ausentes os requisitos da prisão preventiva, REVOGO a prisão preventiva do réu Bruno decretada a fls. 120/123. Expeça-se alvará de soltura.

Vertente ao corréu Odair Cardoso dos Santos, em observância ao artigo 42 da Lei de

Drogas, bem como aos elementos preconizados pelo artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu ostenta antecedentes criminais ruins (F.A. e certidões a fls. 182/187 e 237/253) e, tendo já cumprido pena privativa de liberdade, voltou a delinquir. Isso mostra que tem conduta social reprovável e personalidade voltada à delinquência, já que a mais grave das penas ordinariamente previstas em nossa legislação penal não a intimidou a praticar novo delito. Assim, elevo a pena-base em 1/6 (um sexto), resultando em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, ante a falta de elementos sobre a real situação econômica do réu (CP, arts. 49 e 60). Na segunda fase de dosimetria, atento ao teor do Tema n. 585 do STJ, bem como à multirreincidência do réu, é o caso de se reconhecer a preponderância da agravante, razão pela qual elevo a pena em mais 1/6 (um sexto), atingindo a quantia de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa. Não estão presentes outras agravantes ou atenuantes. Por fim, na terceira fase, entendo que inexistem causas de aumento ou de diminuição da pena. Não incide a benesse prevista no §4º do artigo 33 da Lei de Drogas, pois o réu não preenche todos os predicados legalmente previstos, pois, além da reincidência, a variedade da droga apreendida aliado ao fato de que confessou estar guardando para terceira pessoa revelam que se dedica à atividade criminosa. Nesse sentido: "Não há ilegalidade na negativa de aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, porquanto a quantidade e a natureza da substância apreendida levaram à conclusão de que o paciente se dedica a atividades delituosas, ou seja, não se trata de traficante ocasional" (HC 297447/RS, Ministro JORGE MUSSI, DJe 13/11/2014). E nem se alegue possível bis in idem relativo ao aumento da pena pela reincidência e a não aplicação do aludido redutor, uma vez que este deixou de incidir também em virtude da dedicação às práticas delitivas, tudo em fases distintas da dosimetria. Confira-se: "A valoração da reincidência na segunda etapa da dosimetria, como circunstância agravante, não é incompatível com a sua utilização, na terceira fase, para afastar a incidência da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, porquanto o referido instituto jurídico é sopesado com finalidades distintas em cada fase de fixação da pena, justamente para se alcançar a justa e correta reprimenda necessária para a reprovação e prevenção do delito perpetrado. Precedentes" (HC 214069/SP - Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ - Sexta Turma - DJe 29/11/2013). Desta forma, fixo em definitivo a pena a cumprir de 06 (SEIS) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 680 (SEISCENTOS E OITENTA) DIAS-MULTA, COM O DIA UNITÁRIO NO PISO MÍNIMO LEGAL. Diante do disposto no artigo 2º, parágrafo 1º da Lei nº 8.072/90, deverá iniciar o cumprimento da pena em regime FECHADO. O restante da pena e eventuais benefícios legais deverão ser objeto de análise do juízo das execuções. É importante não perder de vista que a consideração do tempo de prisão provisória do réu (preso em 17/06/2022) não altera o panorama do regime inicial da pena aplicada. Assim, deixo de aplicar o disposto no § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal, pois como bem indica Guilherme de Souza Nucci, "O disposto no §2º do artigo 387 do Código de Processo Penal, permite que o julgador promova o desconto pertinente à detração ao escolher o regime inicial do réu no caso de condenação. Não significa de modo algum que o magistrado deve sempre conceder o regime inicial mais brando, pois se pode considerar como adequado regime inicial mais gravoso, nos termos do art. 59 do Código Penal, indicado pelo art. 33, § 3º. Afinal, somente o juiz da execução penal possui o quadro completo das condenações daquele réu, do seu comportamento carcerário, e do seu merecimento" ("Código de Processo Penal Comentado", 13ª edição, Editora Forense, páginas 805 e 806). Desta forma, melhor que a questão seja analisada pelo Juízo de Execuções Criminais, que certamente disporá de elementos mais substanciais para decidi-la. Inviável a substituição por pena restritiva de direitos, seja pelo fato de estarem ausentes os requisitos previstos nos artigos 44, III, e 77, II, ambos do Código Penal, seja porque o art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90 estabelece que a reprimenda por crime de tráfico de drogas deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, seja, finalmente, porque o art. 44, caput, da Lei nº 11.343/2006, são expressos ao

proibir referido benefício. Filio-me ao entendimento que sustenta a constitucionalidade de tais dispositivos, pelas seguintes razões, algumas delas retiradas da Arguição de Inconstitucionalidade no HC 120.353-SP, julgada em 04.11.2009 pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, Rel. originário Min. Og Fernandes, Rel. para acórdão Min. Ari Pargendler: i) o art. 5º, inciso XLVI, da CF/88, determina que a lei regulará a individualização da pena; ii) o art. 5º, inciso XLIII, da CF/88, estabelece que a lei deverá dispensar tratamento mais gravoso ao crime em questão, destacando também a importância da repressão a esse delito no art. 5º, inciso LI, o qual autoriza a extradição de brasileiro naturalizado comprovadamente envolvido com tráfico de drogas; iii) é perfeitamente possível que o legislador ordinário proíba a substituição da pena por restritiva de direitos, tanto que o art. 44, do CP, veda o benefício para todos os crimes praticados mediante violência ou grave ameaça à pessoa ou com pena superior a 04 anos, ou, ainda, no caso de ser o agente reincidente em crime doloso; iv) o Brasil assinou tratados internacionais se comprometendo a combater o tráfico de drogas; v) o crime de tráfico de drogas, além de ser equiparado a hediondo e ser a principal causa de inúmeros outros delitos patrimoniais, gera efeitos nefastos para a sociedade e para as famílias de bem, de modo que a concessão do benefício, além de ser, no meu entender, incompatível com a sua gravidade, não se mostraria suficiente para a prevenção ou reprovação do delito (CP, art. 59, in fine), gerando ofensa ao disposto no art. 44, III, do CP, além de verdadeira sensação de impunidade nesta pequena e interiorana cidade de Avaré.

Deixo de reconhecer o direito do réu de apelar em liberdade, em observância ao artigo 312 do CPP c/c. artigo 2º, § 3º da Lei nº 8.072/90, pois a gravidade do delito, que vem se alastrando de forma avassaladora também nas pequenas cidades, torna evidente a necessidade da prisão para se garantir a ordem pública. Outrossim, porque o réu respondeu preso ao processo, de sorte que seria um paradoxo colocá-lo em liberdade exatamente depois de receber sentença condenatória. Recomende-se.

Conforme art. 63 da Lei nº 11.343/06 c/c art. 91 do CP, decreto o perdimento de tudo quanto apreendido neste processo. Não tendo havido controvérsia, no curso do processo, sobre a natureza e a quantidade da substância entorpecente ou sobre a regularidade do laudo respectivo, fica determinado, desde já, sua destruição por incineração, na forma da legislação vigente (Lei n. 11.343/06, arts. 33, §§ 1º e 2º, e 58, §1º), no prazo máximo de 30 (trinta) dias, preservando-se fração suficiente para eventual contraprova. Comunique-se à autoridade de polícia judiciária competente, caso isso ainda não tenha sido providenciado.

Registre-se, desde logo, que, em caso de recebimento de eventual recurso de apelação interposto contra a presente, deverá ser expedida a competente guia de execução provisória em nome dos réus/condenados recorrentes, nos termos do que dispõe o art. 9 da Resolução nº 113/2010 – CNJ, para que possa, quando for o caso, obter os benefícios previstos na LEP (sumula do STF, Enunciado nº 716).

Oportunamente, após o trânsito em julgado da presente, adotem-se as seguintes providências: (a) expeça-se guia de execução (definitiva, se o caso) dos condenados; (b) proceda-se ao recolhimento do valor atribuído a título de pena pecuniária, em conformidade com o disposto no artigo 686, do Código de Processo Penal; (c) oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando as condenações, com as devidas identificações, acompanhada de fotocópia desta decisão, para cumprimento do disposto no art. 15, III, da Constituição da República c/c o art. 71, §2º, do Código Eleitoral; (d) oficie-se ao órgão responsável pelo cadastro de antecedentes criminais deste Estado para as anotações necessárias; (e) efetuem-se as averbações de praxe (NSCGJ, Cap. V, itens 22, d, e 23). Custas processuais nos termos da lei.

P.I.C.

Avare, 04 de novembro de 2022.

MARGEM DIREITA